

1514398-50.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munições, ocasião em que a CNH da vítima foi encontrada embaixo do banco do motorista do carro Renault/Clio, placas DMZ 6550, que ele conduzia na oportunidade.

Diante disso, a ofendida foi acionada a comparecer na Delegacia de Polícia, onde reconheceu, pessoalmente, e sem sombra de dúvidas, o denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514398-50.2021.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514398-50.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2264957/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 14885138 - 01º D.P. GUARULHOS, 466679/21/020 - 01º D.P. GUARULHOS, 3158/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2264957 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO, qualificado a fls. 16, porque no dia 14 de março de

2021, por volta das 08h30min, na Rua Jamil João Zarife, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Marcia Freitas de Oliveira, um aparelho celular e uma CNH, a ela pertencentes, além da quantia de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), pertencente à empresa concessionária de ônibus.

Segundo o apurado, na data dos fatos, no ponto situado no metrô Armênia, na cidade de São Paulo, o denunciado adentrou o ônibus da linha 552, com sentido ao Bairro Santos Dumont, na cidade de Guarulhos, e, passando-se por passageiro, sentou-se na parte dianteira do coletivo.

Quando o ônibus chegou à Rua Jamil João Zarife, GABRYEL abordou a vítima Marcia, condutora do ônibus, e, exibindo-lhe uma arma de fogo, tipo revólver, cor preta, anunciou o assalto e exigiu que ela fosse devagar, sob pena de atirar.

Ato contínuo, apoderou-se do celular da vítima e de sua CNH (que estava junto ao aparelho), além da quantia de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), que estava no caixa do ônibus.

Em seguida, o denunciado pulou a catraca e subtraiu pertences de outros passageiros, os quais não foram identificados, tomando rumo ignorado.

Posteriormente, no dia 21 de setembro de 2021, GABRYEL foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munições, ocasião em que a CNH da vítima foi encontrada embaixo do banco do motorista do carro Renault/Clio, placas DMZ 6550, que ele conduzia na oportunidade.

Diante disso, a ofendida foi acionada a comparecer na Delegacia de Polícia, onde reconheceu, pessoalmente, e sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o autor do delito de roubo (cf. auto de reconhecimento a fls. 13).

Denúncia recebida às fls. 34.

Citado pessoalmente (fls. 89), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 93/95).

Ratificado recebimento da denúncia às fls. 102.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva das vítimas e uma testemunha (fls. 219/231).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 157/165).

A Defesa de requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tecendo teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 157/165).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de roubo qualificado ficou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 08/09 e 10/11, auto de exibição e apreensão de fls. 15, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

A vítima Márcia, ouvida em Juízo, narrou o assalto da mesma forma como descrita na denúncia e voltou a reconhecer o acusado, assim como já fizera em sede inquisitorial (fls. 13). Disse que sua CNH, subtraída na data do assalto, foi encontrada dentro do veículo conduzido pelo réu, no dia em que ele foi preso: "Foi vítima do assalto. O assalto ocorreu por volta de oito horas e trinta minutos da manhã. Era apenas um assaltante. Estava armado. O acusado entrou no ônibus e seguiu viagem como passageiro até o ponto do aeroporto. Anunciou e efetuou o assalto, e desceu um ponto após. Foram subtraídos o celular, a CNH e cerca de cento e trinta reais do caixa. Havia passageiros no ônibus. Os passageiros também foram assaltados. Na data do ocorrido não ocorreu a prisão. Realizou o reconhecimento do indivíduo após seis meses. Policiais informaram que a CNH foi encontrada dentro do carro do réu. O reconhecimento foi realizado via foto e pessoalmente na delegacia. O reconhecimento foi positivo. Em audiência reconhece novamente o acusado. O celular avaliado em mil e trezentos reais não foi recuperado. No ato de registro do boletim de ocorrência não se recordou que sua CNH estava junto ao celular, dentro da capinha. Emitiu segunda via da CNH por site. No reconhecimento na delegacia a tatuagem no pescoço do réu chamou a atenção. Não se recorda se havia tatuagens na mão do acusado".

Em se tratando de roubo, a(s) palavra(s) da(s) vítima(s) tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a outros elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Não há qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal operado pela vítima em Juízo.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação

Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Também não se alegue eventual "inobservância" ao item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 que dispõe: "Entendendo o magistrado sobre a necessidade da aplicação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando da comunicação da data e horário da audiência ao estabelecimento prisional, tal circunstância será informada ao estabelecimento prisional para que além do réu, se possível, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança".

Por primeiro, comunicado não é lei, não substitui o Código de Processo Penal nem o regulamenta. Além disso, da leitura atenta do texto por qualquer pessoa de inteligência mediana, depreende-se que o procedimento não é obrigatório. Será utilizado apenas quando o magistrado entender necessária a aplicação do art. 226, CPP, o que não é o caso, como acima esposado.

Não bastasse a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

O policial civil Eugenio, ouvido em Juízo, disse que o acusado foi identificado porque a CNH da vítima foi encontrada dentro do carro que ele conduzia no dia em foi preso por tráfico de drogas. Acrescentou que as imagens das câmeras existentes dentro do coletivo assaltado são muito precárias e não permitiriam qualquer reconhecimento: "É policial civil. Participou da investigação. Por conta de má qualidade das imagens não foi possível identificar o acusado nas filmagens da câmera existente no coletivo. Algumas vítimas foram até a delegacia, porém não reconheceram o acusado devido a qualidade das filmagens. Não se recorda se realizou contato com a vítima Marcia".

Seu colega Levy, em sede inquisitorial, no relatório de investigações de fls. 25 deu a mesma versão, esclarecendo que dia 21 de setembro de 2021, cerca de seis meses após o assalto em tela, GABRYEL foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munições, ocasião em que a CNH da vítima foi encontrada embaixo do banco do motorista do carro Renault/Clio, placas DMZ 6550, que ele conduzia (auto de exibição e apreensão de fls. 15). A vítima foi acionada a comparecer na Delegacia de Polícia, onde reconheceu, pessoalmente o denunciado como sendo o autor do delito de roubo (auto de reconhecimento de fls. 13).

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo depoimento da vítima.

A propósito:

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juiz criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De fato, não se vislumbra por qual motivo os agentes públicos e a vítima prestariam falso testemunho, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

O acusado, tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a autoria do roubo, dando versão fantasiosa aos fatos, alegando que executava um serviço de pintura no dia e horário dos fatos. Ofertou alegação ainda mais estúrdia ao encontro do CNH da vítima dentro do veículo que conduzia, no dia em que foi preso em flagrante, seis meses após o roubo. Disse que sua esposa encontrou a CNH em um ponto de ônibus, e lhe entregou para que levasse até uma agência dos Correios. Por fim, teve a pachorra de negar sua presença na fotografia de fls. 14, onde aparece perfilado com outros indivíduos no reconhecimento pessoal operado na Delegacia: "Tem 20 anos. É amasiado com Samira Gomes. Tem um filho. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Trabalhava como pedreiro, carpinteiro e pintor. Ganhava de mil e quinhentos reais a dois mil reais. Trabalhava autônomo. Não era usuário de entorpecentes. Não tem outras passagens. Não tem passagem como menor de idade. Não praticou o assalto. Na data do ocorrido estava trabalhando como pintor na casa de uma vizinha. Na casa da vizinha Celia mora ela, junto com duas filhas e o marido. Aos fins de semana eles ficavam em casa enquanto fazia o serviço. O veículo Renault Clio em que estava no dia em que foi preso é de sua propriedade. Comprou-o pelo Facebook por dois mil reais. O nome do vendedor era Marcos e residia em Mairiporã. Recebeu apenas o DUT do veículo. Adquiriu o carro em julho de 2021. Sua esposa, três dias antes de ir preso, encontrou a habilitação em cima do banco do ponto de ônibus próximo ao local onde moram. Levaria o documento até uma agência dos Correios. O documento não estava embaixo do banco e sim dentro de uma caixa, junto aos seus documentos. Não conhecia os policiais que o prenderam. Permanece amasiado com a esposa. Tem três tatuagens. A tatuagem do pescoço é o nome da sua mãe. A tatuagem do braço é uma catrina e um samurai. A tatuagem da costela é uma frase. Imagina que a vítima tenha o reconhecido como o autor do roubo pois estava sozinho na sala reconhecimento da Delegacia. Confrontado com a foto do Auto de Reconhecimento de Pessoa fls. 14, alegou não ser ele na foto (!!!????). Tem a tatuagem na mão desde 5 de fevereiro de 2020. Sua esposa é menor de idade e devido a outros afazeres não participaria da audiência. Confirma que fez serviços na casa de Jaqueline em dezembro, sua vizinha, testemunha arrolada pela Defesa".

Além de inverossímeis, as palavras do acusado encontram-se isoladas diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Certos tipos de réus parecem acreditar piamente que seus processos serão julgados por alguma espécie de néscio ou pascácio.

Não apenas sua mentira sórdida e descarada é abominável, mas também o pouco crédito dado pelo réu à inteligência de seus julgadores (Juiz e Desembargadores).

Como já mencionado, o acusado foi reconhecido PESSOALMENTE pela vítima, tanto na Delegacia, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório, teve a desfaçatez de alegar que estava sozinho na sala de

reconhecimento na Delegacia. Devidamente confrontado com a fotografia de fls. 14, onde aparece na Delegacia perfilado com outros dois indivíduos, teve o deslante de alegar não ser a sua pessoa na foto! Patético....

Se não bastasse, a CNH da vítima foi encontrada embaixo do banco do motorista do carro conduzido pelo réu quando ele foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munições, seis meses após o roubo em tela (fls. 15).

É entendimento da jurisprudência que a apreensão da res furtiva em poder do agente evidencia a autoria do crime:

"Prova - Furto - Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração" (TACRIM-SP - Ap. 1.006.721 - Rei. Juiz Renato Nalini)

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - Rel. Roberto Mortari - RJD 18/47)

"Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência." (TACRIM - Ap. 1.318.439/8 - Rel. Juiz Carlos Biasotti - RT 806/572)

A explicação dada ao fato pelo réu é risível. Disse que sua esposa "encontrou" a CNH em um ponto de ônibus e lhe entregou para que deixasse em uma agência dos Correios.

A esposa do réu, aliás, sequer foi arrolada pela Defesa para que "confirmasse" tal versão, prova que seria de fácil obtenção, caso fosse verdadeira.

Ao invés disso, a Defesa preferiu arrolar duas testemunhas, vizinhas do réu, para "corroborar" seu alegado alibi.

Com efeito, não obstante a robustez das provas amealhadas nos autos, o acusado teve a pachorra de, além de negar a autoria do delito, trazer aos autos duas testemunhas para, em vão, tentar confirmar seu alibi, no sentido de que estava prestando um serviço de pintura no dia e horário do assalto ao coletivo.

Célia disse que à época dos fatos, o acusado executava um serviço de pintura em sua residência, aos finais de semana (sábado e domingo) das 07:00h às 17:00h: "É testemunha de defesa. Conhece o acusado. Gabryel. Ele faz serviços de pedreiro aos finais de semana em sua casa. Conhece o réu há cerca de seis anos. Conhece Samira, esposa de Gabryel apenas de vista. Ele iniciou o trabalho de pintura em sua casa no início de março e finalizou por volta do dia vinte de fevereiro. Apenas um dia precisou sair mais cedo em decorrência de problema de saúde da mãe. O expediente era de sete horas da manhã às dezessete horas da tarde. Gabryel trabalhava sozinho. O serviço demorou cerca de um mês para conclusão pois também foi necessário massa corrida. Foi a primeira vez que contratou os serviços do acusado. Soube da prisão do réu por tráfico de drogas. Os trabalhos também eram realizados aos domingos. Na data do fato Gabryel ainda trabalhava no serviço de pintor".

A testemunha Jaqueline, por sua vez, também disse que o acusado trabalhava aos

finais de semana como pedreiro e pintor, no mesmo horário acima mencionado. Disse que, inclusive, o acusado pintou um cômodo da sua casa, mas, “estranhamente”, não se lembra a data: “É testemunha de defesa. É vizinha de Gabryel. Conhece a esposa do acusado. Frequenta a residência do réu. Conhece o casal há cerca de quatro anos. Ele trabalha como pedreiro e pintor. Já fez obra em sua casa. Não se recorda a data. Trabalhou por uma semana. Pintou apenas um cômodo. O expediente era de sete horas da manhã as cinco horas da tarde aos finais de semana. Soube da prisão em flagrante do réu, porém não sabia o motivo. Soube através da vizinhança. Não sabe informar onde era o trabalho fixo durante a semana de Gabryel”.

É evidente que as testemunhas arroladas pelo Defesa mentiram, tentando em vão, mas de forma mendaz, criar um falso álibi para o acusado, suposto “pintor de finais de semana”.

Como já dito, não se vislumbra por qual motivo a vítimas e os policiais prestariam falsos depoimentos, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam.

Cabia à Defesa trazer aos autos, ainda que superficialmente, indício da conduta ilícita dos agentes públicos ou da própria vítima.

Note-se que tem se tornado cada vez mais comum a invocação de prisões forjadas, como forma de ilidir o honesto e competente trabalho de agentes da lei. Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como regra, sendo certo que se trata de exceções, as quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.

É incrível como nos dias atuais a marginalidade, além de mentir descaradamente em Juízo, ainda se sente no direito de incluir em suas mentiras toda sorte de abusos e barbaridades supostamente cometidas por agentes da lei, sem qualquer tipo de prova, inventando as histórias mais absurdas e mirabolantes, e não raras vezes, como no caso em tela, ainda trazem testemunhas mendazes em Juízo.

Como se vê, em que pese a negativa do acusado, esta não merece ser levada em conta, isto porque nada trouxe que afastasse dela a responsabilidade pelo roubo ora apurado, limitando-se a fazer alegações vagas e sem elementos probatórios que as comprovassem, ao contrário das narrativas trazidas pelas vítimas e testemunhas em juízo, que apresentam sequência lógica e coesa.

Assim, diante de elementos de convicção, não resta dúvida de que o proceder dos acusados amolda-se perfeitamente ao delito descrito na denúncia, sendo a sua condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Embora não apreendida a arma utilizada no assalto, a vítima foi categórica ao narrar que o acusado portava uma arma de fogo no momento do roubo.

A palavra firme e segura da(s) vítima(s), no delito de roubo, basta para o reconhecimento da aludida majorante.

A propósito:

STJ “Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima” (RT 841/515)

STJ “É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do

artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT 821/534).

Deve ser reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso formal, devidamente descrita na denúncia, uma vez que o autor do crime, numa só ação subtraiu bens de duas vítimas diferentes: um aparelho celular e uma CNH, pertencentes a vítima Marcia, além da quantia de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), pertencente à empresa concessionária de ônibus.

Sobre o tema, a jurisprudência é clara:

CONCURSO FORMAL - Reconhecimento no crime de roubo - Pluralidade de vítimas, sendo que de cada uma se subtrai um objeto - Ocorre o concurso formal no crime de roubo se, em uma única ação delituosa, existir mais de uma vítima, subtraindo-se, de cada qual, um determinado objeto (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 727.575/4, Julgado em 23/06/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Luiz Ambra, RJDTACRIM 22/93)

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes as penas.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, considerando as circunstâncias, as consequências e a gravidade (em concreto) do delito, bem a personalidade deformada e mendaz do réu. Com efeito, o acusado demonstrou enorme ousadia, pois o assalto em tela foi cometido em um coletivo, à mão armada, durante a manhã, à plena luz do dia, contra uma senhora de que estava trabalhando como motorista de ônibus. Há que se considerar ainda a personalidade deformada, mendaz e antiética do acusado, pois preferiu mentir em seu interrogatório, tentando enganar o julgador (inclusive trazendo em Juízo testemunhas igualmente mentirosas) e demonstrando total falta de arrependimento em sua nefasta conduta.

Aos que defendem, sem envergonhar, que o réu tem "direito" de mentir em seu interrogatório judicial, cito decisão pedagógica, proferida nesta Comarca de Guarulhos em data recente. Na sentença de 14 de março de 2013, que em primeira instância condenou M.B.S. a 20 anos de reclusão pela morte de Mércia Nakashima, o juiz de Direito Leandro Jorge Bittencourt Cano, da Vara do Júri de Guarulhos/SP, aumentou a pena-base do réu devido à sua personalidade mentirosa. O colega Cano escreveu:

"Tem personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais básicos, sendo-lhe indiferente as consequências infaustas de seus atos sobre seus semelhantes. Infelizmente, não existe o crime de perjúrio no ordenamento jurídico pátrio. Por outro lado, não há dúvida sobre o direito ao silêncio, podendo o réu durante o seu interrogatório nada responder sobre uma ou todas as questões que lhe forem dirigidas, sem que isso possa lhe acarretar qualquer prejuízo. Todavia, uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo, outra bem diferente é mentir, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito invocado.

Na verdade, não estamos diante de um direito de mentir, mas simplesmente da não punição criminal da mentira, salvo se a sua postura redundar na inculpação de terceiros, no desvio da investigação para a busca de fatos inexistentes, ou mesmo se consubstanciar na assunção de ilícitos executados por outras pessoas (com o objetivo de inocentar o real criminoso, dando-lhe proteção em troca de uma promessa de recompensa ou qualquer outra espécie de benefício escuso). Com o devido respeito, não se pode tolerar o perjúrio como se fosse uma garantia constitucional, até pelo fato de o réu não precisar mentir para exercer o seu direito ao silêncio.

A verdade é sempre um valor a ser defendido pelo Estado, o qual jamais poderá permitir e estimular a mendacidade.

Esclarecendo, caso silencie, nada lhe acarretará; logo, não precisa mentir. Ao mentir, o acusado o faz de modo intencional, notadamente para enganar o julgador, na espécie, os jurados, e beneficiar-se da própria torpeza, perfídia ou malícia, em detrimento de bens jurídicos relevantes para a Magna Carta e o processo penal. Se o réu não está obrigado a falar, está cristalino que não precisa mentir.

Como ensina Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica –, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

Ora, como a mentira tem por escopo iludir os jurados, ludibriar o “ex adverso”, enganar a coletividade e provocar um erro judiciário, tal circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz-presidente na fixação da pena, nos termos do art. 59 do CP. A mentira jamais poderá ser interpretada como direito ínsito, mas como subterfúgio repudiável ao exercício da atividade investigativa e judicante.

Parafraseando Pedro Reis (Dever de verdade – Direito de mentir. História do pensamento jurídico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa. Coimbra Editora. p. 457 e 462, respectivamente), “é de ter-se sempre em conta que onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira”, pelo que “do direito de calar não decorre um direito de falsear uma declaração”.

Para Antônio Pedro Barbas Homem (O que é direito?, Lisboa. Principia Editora, Reimpressão, 2007, p. 66), a “verdade brilha e guia a nossa liberdade e a nossa vontade”, ao passo que a mentira, ao contrário, “conduz à escuridão e ao vazio”.

Não se exige o heroísmo do acusado de dizer a verdade auto incriminadora, ou seja, o comportamento de dizer a verdade não é imposto, mas isso não quer dizer que exista o direito de mentir.

De acordo com Theodomiro Dias Neto (O direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 19, São Paulo: RT, 1997, p. 187” (“Apud” Thiago Bottino. O direito ao silêncio na jurisprudência do STF. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p. 73), a jurisprudência alemã tem, contrariamente da doutrina, “assumido posição diversa, no que se refere à pena, ao interpretar a mentira como indício da personalidade do acusado”.

Diga-se, por fim, que ao lado dos direitos fundamentais existe uma segunda dimensão, representada pelos deveres fundamentais, isto é, o dever do homem de respeitar determinados valores relevantes para a vida em comunidade, de tal modo que os direitos devem ser os canais institucionais que permitam a realização dos deveres (+ 2 anos).”

Que fique ainda aos acusados a lição do Dr. Vladimir Aras, mestre em Direito Público pela UFPE, professor assistente de Processo Penal da UFBA e membro do Ministério Público Federal, no qual, aliás, o trecho sentença acima também é reproduzido (<http://blogdovladimir.wordpress.com/2013/03/15/enganei-o-juiz-e-me-dei-bem>):

“Enganei o juiz e me dei bem”

Dita a sério, a frase acima seria um acinte, um deboche. Mas muita gente no mundo jurídico brasileiro aceita ouvir histórias da carochinha, do tipo “me engana que eu gosto”.

Eu não. Processo penal é coisa séria; é garantia do réu e instrumento de defesa da sociedade. Não é teatro. Por isto, volto ao tema do suposto “direito” de mentir.

Já houve tempo em que o Superior Tribunal de Justiça, especialmente a 6ª Turma, admitia que um suspeito – por exemplo, um foragido – se identificasse falsamente à autoridade policial para não ser preso. Era, diziam placidamente, uma forma de autodefesa. Mentir para não ser preso seria um direito fundamental do condenado fujão, ainda que se tratasse de um homicida, um estuprador, um latrocida ou um corrupto. “Belo” incentivo do Tribunal da Cidadania...

O mesmo padrão ético ainda é tolerado por aqueles que afirmam, sem enrubecer, que o réu tem “direito” de mentir em seu interrogatório judicial.

Mas nem todo mundo tem a mesma condescendência com o pinoquismo. De São Paulo, veio a boa notícia. Na sentença (aqui), de 14/mar, que em primeira instância condenou M.B.S. a 20 anos de reclusão pela morte de Mércia Nakashima, o juiz de Direito Leandro Jorge Bittencourt Cano, da Vara do Júri de Guarulhos/SP, aumentou a pena-base do réu devido à sua personalidade mentirosa. Cano escreveu:

“Tem personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais básicos, sendo-lhe indiferente as consequências infaustas de seus atos sobre seus semelhantes. Infelizmente, não existe o crime de perjúrio no ordenamento jurídico pátrio. Por outro lado, não há dúvida sobre o direito ao silêncio, podendo o réu durante o seu interrogatório nada responder sobre uma ou todas as questões que lhe forem dirigidas, sem que isso possa lhe acarretar qualquer prejuízo. Todavia, uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo, outra bem diferente é mentir, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito invocado.

Na verdade, não estamos diante de um direito de mentir, mas simplesmente da não punição criminal da mentira, salvo se a sua postura redundar na inculpação de terceiros, no desvio da investigação para a busca de fatos inexistentes, ou mesmo se consubstanciar na assunção de ilícitos executados por outras pessoas (com o objetivo de inocentar o real criminoso, dando-lhe proteção em troca de uma promessa de recompensa ou qualquer outra espécie de benefício escuso). Com o devido respeito, não se pode tolerar o perjúrio como se fosse uma garantia constitucional, até pelo fato de o réu não precisar mentir para exercer o seu direito ao silêncio. A verdade é sempre um valor a ser defendido pelo Estado, o qual jamais poderá permitir e estimular a mendacidade.

Esclarecendo, caso silencie, nada lhe acarretará; logo, não precisa mentir. Ao mentir, o acusado o faz de modo intencional, notadamente para enganar o julgador, na espécie, os jurados, e beneficiar-se da própria torpeza, perfídia ou malícia, em detrimento de bens jurídicos relevantes para a Magna Carta e o processo penal. Se o réu não está obrigado a falar, está cristalino que não precisa mentir.

Como ensina Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica –, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

Ora, como a mentira tem por escopo iludir os jurados, ludibriar o “ex adverso”, enganar a coletividade e provocar um erro judiciário, tal circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz-presidente na fixação da pena, nos termos do art. 59 do CP. A mentira jamais poderá ser interpretada como direito insito, mas como subterfúgio repudiável ao exercício da atividade investigativa e judicante.

Parafraseando Pedro Reis (Dever de verdade – Direito de mentir. História do pensamento jurídico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa. Coimbra Editora. p. 457 e 462, respectivamente), “é de ter-se sempre em conta que onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira”, pelo que “do direito de calar não decorre um direito de falsear uma declaração”.

Para Antônio Pedro Barbas Homem (O que é direito?, Lisboa. Principia Editora, Reimpressão, 2007, p. 66), a “verdade brilha e guia a nossa liberdade e a nossa vontade”, ao passo que a mentira, ao contrário, “conduz à escuridão e ao vazio”.

Não se exige o heroísmo do acusado de dizer a verdade auto incriminadora, ou seja, o comportamento de dizer a verdade não é imposto, mas isso não quer dizer que exista o direito de mentir.

De acordo com Theodomiro Dias Neto (O direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 19, São Paulo: RT, 1997, p. 187” (“Apud” Thiago Bottino. O direito ao silêncio na jurisprudência do STF. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p. 73), a jurisprudência alemã tem, contrariamente da doutrina, “assumido posição diversa, no que se refere à pena, ao interpretar a mentira como indício da personalidade do acusado”.

Diga-se, por fim, que ao lado dos direitos fundamentais existe uma segunda dimensão, representada pelos deveres fundamentais, isto é, o dever do homem de respeitar determinados valores relevantes para a vida em comunidade, de tal modo que os direitos devem ser os canais institucionais que permitam a realização dos deveres (+ 2 anos).”

Reputo acertadíssima a decisão do juiz Cano. Ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na individualização da pena, o julgador destacou a personalidade mendaz do acusado, para aumentar a pena-base.

No artigo “A mentira do réu e o art. 59 do CP”, publicado no livro “Garantismo Penal Integral” (JusPodivm, Salvador, 2009), organizado por CALABRICH, FISCHER e PELELLA (2ª edição no prelo), defendi esta tese. Não estou seguro, mas creio ter sido o primeiro autor brasileiro a sustentar claramente a possibilidade de incremento da pena, na primeira etapa da dosimetria, tendo em conta a mentira do acusado como traço revelador da sua personalidade. Voltei a sustentar a mesma ideia aqui no Blog, no post “O silêncio, a delação e a mentira no processo penal”, de junho de 2012.

Precisamos parar de “cafuné processual”. Se o devido processo legal for respeitado, tal como querem a Constituição e os tratados, não existe motivo para arranjar justificativas para comportamentos antiéticos do réu criminal. Todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination).

Este é o texto constitucional de 1988, este é o direito que se extrai do art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e do art. 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966.

Em todas as democracias ocidentais, assegura-se ao acusado o direito ao silêncio.

Mas em algumas delas, a mentira do réu chega a ser tipificada como crime: o perjúrio (perjury). Nem por isto se invalida a garantia contra a auto-incriminação. As duas regras coexistem.

Exemplificando: o Miranda warning do direito processual penal constitucional norte-americano – advertência derivada do caso Miranda vs. Arizona, de 1966 – presta-se a assegurar o direito do acusado ao silêncio e à assistência de um advogado. Mas se o suspeito renuncia ao direito ao silêncio e resolve falar – o que configura o waiver –, “tudo o que disser” pode ser e será usado contra ele em juízo, inclusive suas mentiras:

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, one will be provided for you by the court.”

Em parte alguma do planeta - deste planeta! - há o direito constitucional de mentir. Em lugar nenhum um réu pode usufruir de um “direito” fundamental de contar lorotas a um juiz, para enganá-lo e se dar bem. Só com base no art. 7º da Lei de Gerson seria possível sustentar um “direito” (direito, vejam bem) tão exótico.

Obviamente, se quiser, o réu pode mentir à vontade. Mas a isto não lhe corresponde um “direito”. Cada ser humano pode usar seu livre arbítrio como bem entender. Mas aprendemos cedo a arcar com as consequências de nossas ações. Em alguns países, o réu que mente responde pelo crime de perjúrio. Aqui o réu mendaz pode ter sua pena-base aumentada por revelar traços negativos de personalidade.

Em qualquer dos países civilizados, o direito ao fair trial, ao devido processo legal, se confirma com as garantias da ampla defesa, do contraditório, da assistência de um advogado ou defensor, com o direito ao duplo grau, ao juiz natural e a um acusador independente e com a prerrogativa de não se autoincriminar, isto é, ficar em silêncio na Polícia ou em juízo.

No dilema entre mentir ou confessar, ao réu criminal basta o direito ao silêncio. Nenhum prejuízo advirá se o acusado calar-se. É a lei. Por outro lado, a mentira é ética e juridicamente repudiável, dela podendo advir consequências nefastas para terceiros e para a sociedade.

“Amicus Plato, sed magis amica veritas” (“sou amigo de Platão, mas mais amigo da verdade”) (Aristóteles).

Não custa lembrar: ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza. É uma lição tão antiga quanto o direito de defesa. A decisão do juiz Cano é pedagógica, mas não para os acusados mendazes. Para os seus colegas juizes, especialmente os que judicam nos tribunais! Por favor, senhores magistrados criminais: não tolerem a mentira como um “direito”. A ninguém deve ser dado enganar, ludibriar, iludir ou falsear. A mentira chancelada pela Justiça equivale a um erro judiciário. Erra-se quando se condena um inocente. Erra-se quando se absolve um culpado. Neste caso, a mentira prejudica direitos das vítimas e desprotege a sociedade. Mentir não é um direito fundamental do acusado! É hora de revogar este artigo da Lei de Gerson.

Façam como o juiz de Direito de Guarulhos. O acusado não teve ocasião de dizer-lhe a desafortada frase que dá título a este post. Por enquanto, este réu entrou pelo cano. Ainda cabe recurso.

Em tempo

Depois que publiquei este post, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu dar uma lição aos pinóquios. Em acórdão proferido pela 3º Grupo Criminal em julho de 2014 e relatado pela desembargora Bernadete Friedrich, a Corte gaúcha manteve a

condenação do recorrente, que fora considerado culpado do crime do art. 307 do CP (falsa identidade). Ao ser abordado pelas autoridades, o inofensivo contador de histórias identificou-se falsamente para Polícia, para evitar a prisão. Veja:

EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSA IDENTIDADE. Caso em que o agente atribuiu a si falsa identidade com o intuito de livrar-se de detenção policial, somente vindo a ocorrer a sua verdadeira identificação dois dias após o fato. Inviabilidade do reconhecimento do mero exercício regular do direito de autodefesa ou da existência de crime impossível. Abuso do direito de autodefesa que caracteriza o delito previsto no art. 307 do CP. Pacificação da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Embargos infringentes desacolhidos. Unânime (TJ/RS, 3º GC, EI 0394123-53.2013.8.21.7000, j. em 18/07/2014).

Tal decisão está em linha com a posição do STF no RE 640.139 com repercussão geral:

CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPLICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes." (STF, RE 640139 RG, Rel. Dias Toffoli, julgado em 22.09.2011).

Como se vê, a estratégia do réu não deu certo. Isto não é direito de autodefesa. É pura "esperteza" e no mau sentido".

Face à atenuante da menoridade, reduzo a pena em 1/6 totalizando 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Configurado o concurso formal, causa de aumento de pena prevista no art. 70, pela prática do mesmo crime por duas vezes, aumento a pena corporal em 1/6, fixando-a definitivamente em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

A pena pecuniária é fixada em 20 dias-multa para cada delito, totalizando 40 dias-multa no piso mínimo, na forma do art. 72, do Código Penal.

Nos termos do art. 59, c.c. os artigos 311, 312 e 387, parágrafo único, do Estatuto Adjetivo, considerando a extrema gravidade do ilícito praticado (dentro de um coletivo, durante a manhã, com utilização de arma de fogo), que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, portanto a merecer repressão exemplar, deixo de lhe conceder quaisquer benefícios, inclusive o de recorrer em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua periculosidade e forma de proceder.

A fixação de regime mais brando ao acusado seria desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

REGIME INICIAL FECHADO . A alegação de que o regime prisional mais gravoso foi fixado com base na gravidade em abstrato do crime não encontra fundamento, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, o que, inclusive, motivou o aumento da pena-base. Inteligência do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, caput e inciso III, ambos do Código Penal. Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 88493 -JULGAMENTO: 30/05/2006)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "Habeas corpus" indeferido. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 74301 - ACÓRDÃO MESMO SENTIDO: HC 68988 ANO-1991 UF-SP TURMA-02 N. PP-012 Min. MARCO AURÉLIO DJ 24-09-1999 PP-00026 EMENT VOL-01964-01 PP-00202 RAC-MIN-CARLOS VELLOSO - JULGAMENTO: 29/10/1996)

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO, já qualificado, por incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado, cada qual, a pena de 09 (nove) anos, e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 40 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

II - extração de cópias digitais da denúncia, depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, bem como desta decisão, remetendo-se ao Ministério Público local para averiguação da prática do crime de falso testemunho por CELIA APARECIDA GOMES FERREIRA e JAQUELINE BARBOS DA SILVA neste processo.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - remessa de cópia desta decisão às vítimas, com endereços nos autos;

II - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a sua imediata transferência para o regime prisional imposto;

III - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 21 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA